

二、组织赌博的行为人购买房卡的支出不应从犯罪数额中予以扣除

在利用合法娱乐平台创建房间用于赌博类开设赌场犯罪的违法所得数额认定上，通常来说，“违法所得”是指行为人在违法犯罪活动中违法所得的一切财物，不应当将所谓的犯罪成本予以扣除。犯罪所得与非法获利的内涵是一样的，均指犯罪行为人的犯罪收入的总和，而不能理解为“利润”。法律对此类行为持否定性评价，决定此类行为人由此而获得的经济利益都是非法的。至于行为人为了实施犯罪行为而付出的成本，都属于犯罪成本，依法不能在犯罪所得中予以扣除。因此，除非有司法解释对某类案件有特殊考量(如非法经营罪)，犯罪成本原则上不应予以扣除。本案中，购买房卡并支付房费是犯罪分子实施开设赌场行为的必要条件，该部分支出不应在非法获利总额中予以扣除。

编写人：河北省高级人民法院 徐翠翠

河北省保定市中级人民法院 赵炎

(二) 妨害司法罪

24

允诺他人帮忙脱罪的行为认定①

——董某某、汤某某妨害作证案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省淮安市中级人民法院(2021)苏08刑终295号刑事裁定书

①入库案例，参见人民法院案例库2023-05-1-291-001。

2. 案由：妨害作证罪

【基本案情】

2017年6月，黄某、徐某及董某（系被告人董某某、汤某某之子）经合谋，租赁某处门面房共同出资经营某养生会所。2017年12月19日，民警在对某养生会所检查时发现会所内有组织卖淫行为，并于当日立案侦查。2017年12月20日，黄某、徐某至董某家中商量对策，被告人董某某向黄某、徐某允诺利用社会关系帮黄某、徐某脱罪，并要求二人归案后不要供出董某参与某养生会所经营的犯罪事实。因此黄某、徐某在归案后供述其二人是某养生会所的老板，未提及董某。2018年4月，被告人董某某、汤某某为使知晓案情的黄某1（系黄某父亲）隐瞒董某参与组织卖淫的犯罪事实，商定给予黄某160万元作为补偿，并将上述款项存入相关银行账户。2019年4月25日，黄某、徐某因犯组织卖淫罪被分别判处有期徒刑十一年、十年。2019年8月12日，徐某于在服刑期间供述董某参与组织卖淫的犯罪事实；2019年9月5日，黄某亦供述上述事实。2019年9月12日，公安机关于将董某抓获归案。2020年10月23日，董某因犯组织卖淫罪被判处有期徒刑十年六个月。

【案件焦点】

1. 妨害作证罪中的“购买”是否包含非物质性利益，如何对行为人“允诺他人帮忙脱罪”行为进行定性；2. 未进入刑事诉讼程序但知晓案情的人，能否认定为妨害作证罪中的“证人”；3. 对妨害作证罪中“他人”的范围如何理解。

【法院裁判要旨】

江苏省淮安经济技术开发区人民法院经审理认为：妨害作证罪中的“证人”不限于狭义的“证人”，包括被害人、鉴定人、翻译人等，徐某、黄某、黄某1均知情董某犯罪事实，对于董某案来说均属于“证人”。徐某、黄某因受董某某允诺帮忙脱罪的影响，未如实供述董某犯罪事实，董某某的行为实质

上妨害司法机关的正常诉讼活动，其行为已构成妨害作证罪。被告人董某某、汤某某为使黄某1继续隐瞒董某参与经营某养生会所的事实，将60万元打入相关银行账户，二名被告人以购买的方式阻止证人作证，均已构成妨害作证罪。

江苏省淮安经济技术开发区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条及第六十四条之规定，作出如下判决：

- 一、被告人董某某犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年；
- 二、被告人汤某某犯妨害作证罪，判处拘役三个月；
- 三、已被冻结的账户存款人民币60万元予以没收，上缴国库。

一审宣判后，二名被告人提起上诉。董某某提出允诺他人帮忙脱罪的行为不构成妨害作证罪。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，法院予以确认。江苏省淮安市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款在“暴力、威胁、购买”之后还使用了“等”字，说明除列举的上述三种阻止证人作证或者指使他人作伪证的方法外，行为人通过其他积极的作为阻止证人作证或者指使他人作伪证的方法也应属此列。本案中，徐某、黄某、黄某1知晓案情，均可成为妨害作证罪的犯罪对象，上诉人董某某向徐某、黄某允诺帮忙脱罪的行为，以及两名上诉人对黄某1实施的金钱购买行为，妨害了正常的司法诉讼程序，两名上诉人的行为均构成妨害作证罪。上诉人的上诉理由不能成立。

江苏省淮安市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、董某某“允诺他人帮忙脱罪”的行为与暴力、威胁、购买具有同质性，应当以妨害作证罪中的其他方法对该行为进行评价

（一）妨害作证罪中的“购买”不包含非财产性利益

第一，妨害作证罪中的“购买”一词重点是“贿”，“贿”对应的是财物、

财产性利益，并不包含非财产性利益。第二，结合其他相关法条，能进一步阐明“贿赂”的规范意旨中不包含财产性利益。例如，《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款规定，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定，贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益……由此可见，贿赂犯罪中“贿”是可以用金钱来衡量的，非财产性利益则应然地不能被包含在内。

（二）“允诺他人帮忙脱罪”行为可以以妨害作证罪中的其他方法来评价

从实现刑法规范法益保护目的角度考虑，当行为人实施的行为方法如唆使、嘱托、请求、引诱等行为，足以阻止证人作证或指使他人作伪证，该类行为方法对国家司法机关的正常诉讼活动和公民依法作证的权利的侵害，与暴力、威胁、贿赂行为具有同质性，应当地被涵摄至妨害作证罪“等方法”法律语义中。这种解释既不偏离其基本语义的基础，又兼顾多种价值之间的平衡，即在达到刑法保护人民、惩治犯罪的立法目的的同时，又确保解释结论能够得到民众内心的认同与遵从。

二、未进入刑事诉讼程序但知晓案情的黄某1,可以被认定为妨害作证罪中的“证人”

第一，从《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第七十五条两则法律条文可知，凡是知道案件情况的人都应当属于“证人”的范围。第二，从刑法规范的目的角度考察“证人”的内涵。妨害作证罪位于刑法分则第六章第二节“妨害司法罪”中，该节主要规制妨害国家司法机关正常诉讼活动、破坏国家司法权行使的行为。本案从客观要素上来看，董某某的行为直接指向知晓案情的黄某1,行为方式为以金钱贿赂黄某1;主观要素上，董某某追求的是董某不被司法机关发现犯罪事实、逃避法律责任的结果。故而黄某1虽然未进入诉讼活动，但董某某贿赂的行为实质上损害司法客观公正性，其“证人”的身份具有不可替代性，实质上属于该案“潜在证人”。

